

刑法
No.338

H22-11

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、甲に（ ）内の犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、質権者乙の委託を受けて質物である高級腕時計を保管していたが、乙に無断で、これを、質権の被担保債権の債務者で同腕時計の所有者でもある丙に返した。(委託物横領罪)
- イ. 甲は、出資金名目で金をだまし取ろうと考え、乙に対し、架空の投資案件を持ちかけたところ、乙は、甲の話が嘘であることに気付いたものの、甲が金に困っているのに同情して現金を甲に渡した。(詐欺既遂罪)
- ウ. 甲は、乙社に勤務し、同社の取引先からの集金業務に従事していたところ、取引先から現金50万円を集金した後、これを自己の借金の返済に充てようと思い付き、上司に「集金の途中でひったくりに遭った。」と嘘の報告をし、50万円を同社に納めるのを免れた。(業務上横領罪)
- エ. 甲は、偽札を作る意思がないのに、乙に対し、一緒に偽札を作ることを持ちかけた上、偽札を作る機材の購入資金にすると嘘を言って資金の提供を求め、その旨誤信した乙から同資金として現金の交付を受けた。(詐欺既遂罪)
- オ. 甲は、乙社の出張所に一人で勤務し、所長として同出張所の電気機器の使用・管理や光熱費の支払事務などを任されていた。甲は、毎夜、趣味の夜釣りをするため、乙社の承諾を得ずに、同出張所のコンセントに自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用した。(業務上横領罪)

No338

詐欺罪と横領罪

正答率

H22-11

正解

ア 2

イ 2

ウ 1

エ 1

オ 2

23%

ア 成立しない ★

本記述では、所有権の侵害がなく、質権の侵害があったにすぎない場合に、委託物横領罪（252条1項）が成立するかが問題となる。この点、判例は、252条1項の犯罪の成立には、必ず他人の所有権に対する侵害のあることが必要で、質権者より質物の保管を委託された者が、ほしいままにこれをその所有者に交付する行為は、横領罪ではなく、背任罪を構成するとしている（大判明44.10.13）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、委託物横領罪の保護法益は、所有権と委託関係であることから、質権を侵害しても委託物横領罪は成立しないということを挙げている。本記述では、質権者乙から委託を受けて質物である高級腕時計を保管する甲は、乙に無断で、これを質権の被担保債権の債務者で同腕時計の所有者である丙に返すことにより、乙の質権を侵害している。しかし、これにより、誰の所有権も侵害されていない。したがって、本記述では、甲に委託物横領罪は成立しない。なお、甲は、乙のために質物の保管義務を負う者であるから、図利加害目的が認められれば、質物の丙への返還行為は、任務違背行為として、背任罪を構成する可能性がある。

イ 成立しない

本記述では、錯誤に基づかない交付行為が行われた場合に、詐欺既遂罪（246条1項）が成立するか問題となる。この点、判例は、欺罔行為をなしたものの相手方が錯誤に陥らなかった場合は、詐欺未遂罪を構成し、その後、被告人が欺罔行為と因果関係なく金員を受領しても、詐欺既遂罪を構成することはないとしている（大判大11.12.22）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、詐欺とは、人を欺いて財物を交付させ、その占有を取得する行為であるから、詐欺罪が成立するためには、欺罔行為、錯誤、交付行為、財物移転との間に因果的連鎖があることが必要であるということも挙げている。本記述では、乙は、甲の話が嘘であることに気がつきつつ、甲が金に困っているのに同情して現金を甲に渡している。よって、本記述の場合は、乙は錯誤に陥らなかったため、甲の欺罔行為と乙の交付行為との間に、因果的連鎖が認められない。したがって、本記述では、詐欺未遂罪が成立するにすぎず、甲に詐欺既遂罪は成立しない。

ウ 成立する

本記述では、まず、集金業務を委託された者が、集金した金銭を委託者に納めることを免れた場合に、業務上横領罪（253条）が成立するかが問題となる。すなわち、民事法上の金銭の「占有と所有の一致」原則によれば、集金した金銭の所有権は甲に認められることになるため、当該金銭が「他人の物」といえるかが問題となる。この点、判例は、商業使用人が主人のために売掛代金の取立てをなした金銭を自己の用途に消費した事案において、その保管する金銭の所有権は主人に帰属するため、被告人の行為は自己の占有する他人の物を不正に領得したものに外ならないとして、横領罪の成立を肯定している（大判大11.1.17）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、民事法上、動的安全を保護するための「占有と所有の一致」原則は、内部的な所有権保護を目的とする刑法上の委託物横領罪の規定の解釈には妥当しないということを挙げている。本記述では、甲は、乙社の委託を受けて、取引先から集金50万円を集金しているところ、「占有と所有の一致」原則は刑法上適用されないため、50万円の所有権は委託者乙社に認められる。よって、集金50万円は「他人の物」に当たる。そして、横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいうところ、甲は、自己の借金の返済に充てようと思ひ付き、嘘の報告により、50万円を同社に収めるのを免れているため、50万円を横領したものと認められる。また、ここでいう業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいうところ、甲は、乙社の委託を受けて、集金業務に付随して金銭を保管することを内容とする職務をなすものであるから、業務者に当たる。したがって、本記述では、

甲に業務上横領罪が成立する。なお、甲は、横領の手段として、嘘の報告をして本人を欺いているため、詐欺罪の成否が問題となる。自己の占有する他人の財物を横領するに当たり欺罔手段が用いられた事案において、判例は、欺罔は横領の手段であるため、委託物横領罪が成立し、詐欺罪は成立しないとしている（大判明43.2.7）。よって、本記述では、甲に、業務上横領罪が成立するにすぎず、詐欺罪は成立しない。

エ 成立する

本記述では、通貨偽造資金の提供のように不法原因給付に当たる場合、民法708条により、資金の返還を請求できなくなるため、詐取されても詐欺既遂罪（246条1項）が成立しないのではないかが問題となる。この点、紙幣を偽造する資金として金員を詐取した事例において、判例は、詐欺既遂罪の成立を肯定している（大判明42.6.21）。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、民法上の返還請求権がなくても、交付する物自体には何ら不法性は存在せず刑法上は保護すべきであるから、詐欺罪の成立を認めるべきであるということを挙げている。本記述では、甲の交付が、たとえ通貨偽造資金の提供として不法の原因に基づくものであっても、欺罔に基づく処分行為により現金の交付がなされている以上、詐欺罪の成立は妨げられず、詐欺既遂罪が成立する。したがって、本記述では、甲に詐欺既遂罪が成立する。

オ 成立しない

本記述では、業務上横領罪（253条）の客体に、電気が含まれるかが問題となる。この点、横領の罪（刑法第38章）は、窃盗罪や詐欺罪と異なり、電気を財物とみなす規定である245条を準用していない。よって、財物概念の明確性という見地から財物を有体物と解する通説の立場からは、電気は横領罪の客体になり得ない。本記述では、甲は、乙社の承諾を得ずに、趣味の夜釣りのために自己の集魚灯の電源コードを差し込んで電気を使用しているものの、電気は横領罪の客体になり得ない以上、業務上横領罪は成立しない。したがって、本記述では、甲に業務上横領罪は成立しない。

刑法
No339

H22-20

(配点：3)

月 日

月 日

次の【事例】における甲の罪責を判例の立場に従って検討し、後記アからエまでの【罪名】のうち、その罪名に係る犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、乙及びその妻子全員が1週間の旅行に出ていて留守であると聞いていた乙宅に、窃盗の目的で侵入し、金庫を開けたところ、乙の妻子は旅行中だったものの、一人で在宅していた乙に発見され、「泥棒」と叫ばれた。甲は、捕まっては大変だと思い、乙にナイフを突き付け、「静かにしろ。」と言ったところ、乙は、慌てて逃げ出そうとして転倒し、暖炉の角に頭部をぶつけた結果、脳内出血を起こして死亡した。

甲は、乙の死亡を確認した上、金庫の中にあった多量の宝石と多額の現金を奪った後、犯行の痕跡を消し去ろうと考えて乙宅に火を放ち、乙宅は全焼した。

その後、甲は、上記宝石を丙に売却することとしたが、その際、上記事情を知る丁に依頼して、丁が運転する自動車に乗り、丁と一緒に同宝石を丙宅まで運搬した。

【罪名】

- ア. 強盗致死罪
- イ. 証拠隠滅罪
- ウ. 非現住建造物等放火罪
- エ. 盗品等運搬罪

ア 成立する

本事例において、「強盗が人を死亡させた」として甲に強盗致死罪（240条後段）が成立するかが問題となる。まず、甲は、窃盗の目的で乙宅に侵入し金庫を開けており、窃盗の実行に着手している（235条、243条）。次に、甲は乙に「泥棒」と呼ばれ、捕まっては大変だと思い、乙にナイフを突きつけて「静かにしろ」と言っていることから、事後強盗罪（238条）が成立するかが問題となる。この点、財物を取り返されることを防ぐ目的の場合は窃盗が既遂となっていることが前提となるが、逮捕を免れる目的での事後強盗の主体は窃盗未遂犯も含むとされるので（東京高判昭24.12.10）、甲は「窃盗」に当たる。そして、「窃盗」たる甲が、乙に捕まっては大変だとの「逮捕を免れる」目的で、乙にナイフを突き付け「静かにしろ」と言うという乙の反抗を抑圧するに足る「暴行」・「脅迫」を行っていることから、甲は「強盗」として取り扱われ、強盗致死罪の主体となる（238条）。もっとも、乙は直接甲の暴行・脅迫によって死亡したわけではない。そこで、死の結果は強盗罪における暴行・脅迫によって生じる必要があるのか問題となる。この点、240条は、強盗の際、しばしば人の死傷という残酷な結果が生じることに着目した加重処罰規定である。そのため、死の結果が強盗の機会に生じたと認められる場合にも、強盗致死罪は成立すると解される（最判昭24.5.28、百選Ⅱ〔第7版〕44事件）。本事例では、甲の行為により乙は慌てて逃げ出そうとして転倒し、暖炉の角に頭をぶつけ死亡している。よって、「強盗」たる甲が、強盗の機会に「人を死亡させた」といえる。したがって、甲の行為につき強盗致死罪が成立する。

イ 成立しない ★

本事例において、甲に証拠隠滅罪（104条）が成立するかが問題となる。この点、証拠隠滅罪の客体は「他人の」刑事事件に関する証拠である。「他人」とは自己以外の者をいい、自己の刑事事件に関する証拠は証拠隠滅罪の客体とはならない。その理由として、証拠隠滅罪は、証拠の隠滅行為により刑事事件の捜査・審判を誤らせようとする者を処罰する規定であるところ、犯人自身の証拠隠滅行為も刑事司法作用を侵害していることは疑いないが、①犯人自身の証拠隠滅行為は期待可能性が少なく強い非難を向けることができない、②防御権の範囲として政策的に保護すべきであるということなどが挙げられている。よって、甲は、「自己の」強盗致死事件の犯行の痕跡を消し去ろうとして乙宅を全焼させているが、「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅したという要件を満たさない。したがって、甲の行為につき証拠隠滅罪は成立しない。

ウ 成立しない

本事例において、甲は放火して「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建築物」を焼損したとして、非現住建築物等放火罪（109条1項）が成立するかが問題となる。まず、甲は、乙の死亡後「現に人がいない」乙宅に火を放ち全焼させている。しかし、「現に人が住居に使用」している（現住性）とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用していることをいうところ、旅行のために家を空けていたとしても使用が断続していれば現住性は否定されないとされる。判例も、競売手続の妨害目的で従業員を交替で泊まり込ませていた家屋につき、放火を実行する前に上記従業員らを旅行に連れ出している、同家屋に日常生活に必要な設備、備品等があり、従業員らが犯行前の約1か月半の間に十数回交替で宿泊し、旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと認識していたなどの事実関係の下では、上記旅行中の放火行為時においても、上記家屋の使用形態に変更はなかったとして同家屋の現住性は失われていないとしている（最決平9.10.21、百選Ⅱ84事件）。本事例では、乙の妻子は旅行中だったものの、その旅行は1週間だけの予定であることから、使用形態に変更はないといえる。そのため、乙宅は現に人の起臥寝食の場所として日常使用されており、

「現に人が住居に使用」している建造物であるといえる。よって、「現に人が住居に使用せず」という要件を満たさない。したがって、甲の行為につき非現住建造物等放火罪は成立しない。

エ 成立しない

本事例において、甲に盗品等運搬罪（256条2項）が成立するかが問題となる。この点、甲は、自己が奪った宝石を丁と一緒に運搬しているが、甲は宝石を強盗（ないし窃盗）した本犯であるため、共同していた運搬行為は不可罰的事後行為とされ、処罰されない（最判昭24.10.1）。状態犯たる前者の犯罪でその後の違法状態は評価し尽くされているといえるからである。したがって、甲の行為につき盗品等運搬罪は成立しない。